

1503650-54.2022.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Dispõe o art. 7 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, internalizado pelo Decreto presidencial 592/92:

Ninguém poderá ser submetido à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503650-54.2022.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503650-54.2022.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

FERNANDO DONIZETTI SAVI e outro

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de FERNANDO DONIZETTI SAVI, já qualificado nos autos, como incurso no art. 155, § 4º, inciso II e IV, do Código Penal e no art. 1º, inciso I, alínea "b", da Lei nº 9,455/97 em concurso material de infrações, afirmando que em 07 de julho de 2022, por volta de 22h40min, na rua Elen Margareti Kaiser, nº 135, Jardim Alto da Serra D'Água, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, em concurso de agentes e unidade de desígnios com Mariana de Jesus Matos, que estava sob coação física e moral irresistível, pois segundo relatos de Mariana, Fernando teria obrigado ela a participar do furto sob a promessa de lhe agredir, subtraiu, para si, 13 metros de fios de cobre de 16mm, avaliados em R\$ 164,45, pertencentes a Dionísio Bragagnolo. Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "FERNANDO é contumaz autor de furtos nesta cidade, sendo reincidente específico no mencionado delito (cf. declarações à fl. 05 e certidão e folha de antecedentes às fls. 33/38 e 39/44) e, mais recentemente, tem constrangido sua companheira Mariana de Jesus Matos, mediante violência física e, por corolário, sofrimento psicológico, a com ele praticar tais delitos, tendo ela afirmado que "... participou do furto porque foi obrigada e toda vez que se recusa é agredida pelo companheiro, possuindo

inclusive diversas lesões na cabeça em razão de agressões do companheiro" (cf. declarações à fl. 11). E, agindo com este modus operandi, na data dos fatos FERNANDO se dirigiu ao local dos fatos com sua companheira Mariana, que mais uma vez estava sob sua coação física e moral irresistível e, aproveitando-se da falta de vigilância dado o horário noturno, escalou o poste do imóvel/terreno pertencente à vítima Dionísio Bragagnolo e subtraiu a fiação que ali passava, tratando-se de 13 metros de fios de cobre de 16mm. Em seguida, o denunciado colocou os objetos subtraídos na mochila/bolsa da companheira Mariana e ambos deixaram o local. Todavia, policiais militares foram informados do furto em andamento e, em patrulhamento pelas imediações, localizaram o casal FERNANDO e Mariana, cujas características coincidiam com as repassadas, no que aquele, ao avistar a viatura policial, imediatamente empreendeu fuga adentrando numa região de mata. Mariana, que permaneceu no local, foi então abordada e, no interior da mochila/bolsa que ela carregava, foi apreendida a res furtiva. O exame médico de fls. 21/22 apontou a presença de lesões corporais em Mariana, tendo esta afirmado em audiência de custódia que são decorrentes dos ferimentos causados por FERNANDO para obrigá-la a participar dos furtos."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

A Lei 9.455/97 assim regula o delito de tortura:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

- a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
- b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
- c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

Determina o art. 5º da Constituição:

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
(...)

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Dispõe o art. 7 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, internalizado pelo Decreto presidencial 592/92:

Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu livre

consentimento, a experiências médicas ou científicas.

Dispõe o art. 5.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, internalizada pelo Decreto presidencial 678/92:

Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.

A Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio Resolução 3452, de 09/12/1975, conceitua em seu art. 1º a tortura enquanto prática do estado contra o cidadão. O desvalor emitido pelo órgão supremo da ONU incide sobre penas ou sofrimentos graves (físicos ou mentais) com o fim de obter uma informação ou confissão, punir um ato ou intimidar pessoas.

1. Para os efeitos da presente Declaração, entende-se por tortura todo o acto pelo qual um funcionário público, ou outrem por ele instigado, inflija intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos graves, físicos ou mentais, com o fim de obter dela ou de terceiro uma informação ou uma confissão, de a punir por um acto que tenha cometido ou se suspeite que cometeu, ou de intimidar essa ou outras pessoas. Não se consideram tortura as penas ou sofrimentos que sejam consequência unicamente da privação legítima da liberdade, inerentes a esta sanção ou por ela provocados, na medida em que estejam em consonância com as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos

2. A tortura constitui uma forma agravada e deliberada de pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante.

Por sua vez, a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, internalizada pelo Decreto presidencial 40/91, conferiu extensão maior ao conceito de tortura incluindo também as motivações discriminatórias de qualquer natureza:

Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.

Como se vê pela redação da lei nacional, não se trata de crime necessariamente próprio, podendo ser cometido por qualquer um (a depender da modalidade). Por esta razão Nucci (cf. Leis penais e processuais penais comentadas, glosas 1 e 5) propõe um conceito mais abrangente de tortura:

Qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico, ou mental, contínuo e ilícito, para a obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão.

E não há qualquer antinomia entre o direito nacional e o internacional.

1. O conceito de tortura, tomado a partir dos instrumentos de direito internacional, tem um viés estatal, implicando que o crime só poderia ser praticado

por agente estatal (funcionário público) ou por um particular no exercício de função pública, consubstanciando, assim, crime próprio.

2. O legislador pátrio, ao tratar do tema na Lei n. 9.455/1997, foi além da concepção estabelecida nos instrumentos internacionais, na medida em que, ao menos no art. 1º, I, ampliou o conceito de tortura para além da violência perpetrada por servidor público ou por particular que lhe faça as vezes, dando ao tipo o tratamento de crime comum.

3. A adoção de uma concepção mais ampla do tipo, tal como estabelecida na Lei n. 9.455/1997, encontra guarida na Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que ao tratar do conceito de tortura estabeleceu -, em seu art. 1º, II -, que: o presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo; não há, pois, antinomia entre a concepção adotada no art. 1º, I, da Lei n. 9.455/1997 - tortura como crime comum - e aquela estatuída a partir do instrumento internacional referenciado.

REsp 1738264/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 14/09/2018.

O inciso I trata dos casos envolvendo violência (desforço físico) ou grave ameaça (promessa de mal grave, injusto e iminente), diferenciando-se tão somente quanto às motivações descritas em suas alíneas.

A "tortura para a prática de crime" consuma-se independentemente do iter criminis do crime-objeto, bastando o emprego da violência ou grave ameaça contra a vítima. Se o crime-objeto vem a ocorrer, responderá o agente em concurso material de infrações (pois a tortura já estará consumada quando a execução do crime-objeto se iniciar); a vítima, se submetida a uma violência física sem possibilidade de saída (vis absoluta), não poderá ter contra ela imputada sequer uma ação (tratar-se-á de coação, situação na qual um terceiro age por ela e a ele é imputada a ação) - implicando atipicidade, estando os demais casos abrangidos pela irresponsabilidade penal nos termos do art. 22 do Código Penal (excludente da culpabilidade da coação moral irresistível). A pessoa torturadora, nesse contexto, é o "autor mediato". As infrações do inciso I consomem-se tão só com a realização do constrangimento e causação do sofrimento, independentemente se a motivação encontrou sucesso por meio da conduta da vítima.

Os tipos dos incisos I e II exigem um elemento subjetivo específico. No caso, provocar ação criminosa

Aliás, apesar de algumas críticas doutrinárias, a exigência de elemento subjetivo específico guarda correspondência com o âmago do conceito de tortura, cuja reprovabilidade maior está justamente em ignorar a dignidade humana do outro, tratando-o como objeto ou instrumento por meio da imposição de um sofrimento. Por esta razão um fato que, em princípio, poderia ser enquadrado como lesão corporal, uma infração eventualmente de menor potencial ofensivo, passa a ter tratamento tão mais gravoso. Decerto que atingir a incolumidade física de outro é reprovável; no entanto, se este sofrimento imposto à vítima tem por objetivo reduzi-la a um objeto ou instrumento, o ataque à integridade física passa a ser apenas um aspecto de uma atitude ainda mais reprovável que é a negação da dignidade do outro enquanto ser.

A depender da finalidade envolvida pelo agente a lei exigirá para a caracterização da tortura um sofrimento especial, mais intenso (inciso II) ou até mesmo o pressuporá em razão de uma acentuada vulnerabilidade (cf. art. 5º, inciso XLIX, da Constituição) da vítima (§1º).

Ficou comprovada a existência do crime de tortura para a prática de crime (constrangimento mediante emprego de violência física causando sofrimento físico na vítima para que ela praticasse ação de natureza criminosa consistente na subtração de patrimônio de terceiros) e sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10,

pela ficha de atendimento hospitalar de fls. 21/22 e, sobretudo, pela prova oral colhida.
A autoria também é certa.

Já o artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.
Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)
"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

O entendimento firmado no Tema 934 apenas seguiu a jurisprudência do STF. No julgamento do RE 102940, o voto do relator, Min. Moreira Alves, direcionou-se para igualar o marco temporal da consumação do delito criminal com o delito civil (vício da posse), por isso, o repetido termo "inversão da posse". Nesse sentido é válida a lição do Desembargador Francisco Loureiro sobre a cessação da clandestinidade:

A posse é clandestina (clam) quando se adquire via processo de ocultamento em relação àquele contra quem é praticado o apossamento (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit., p. 23). É um defeito relativo: oculta-se da pessoa que tem interesse em retomar a posse, embora possa ser ela pública para os demais. Na violência, retira-se o poder de reação do possuidor, que conhece a agressão à sua posse. Na clandestinidade, o possuidor não percebe a violação de seu direito, e por isso não pode reagir. Questão relevante é saber se para cessar a clandestinidade deve o esbulhador ter ciência inequívoca de que a coisa acha-se nas mãos do possuidor injusto ou, em vez disso, basta que o novo possuidor não mais oculte sua conduta. O melhor entendimento é que não há necessidade de que a vítima tenha efetivo conhecimento do esbulho, mas que o esbulhador torne possível à vítima conhecê-lo (Pinto, Nelson Luiz. Ação de usucapião. São Paulo, RT, 1987, p. 107-8). Torna-se pública a posse quando nasce para a vítima a possibilidade de conhecer o esbulho. Loureiro, Francisco Eduardo. Código civil comentado. 8ª ed., Barueri, Manole, 2014, p. 1070.

Portanto, considera-se invertida a posse a partir do momento em que se torna possível à vítima saber do ocultamento; momentos posteriores, como a fuga com a coisa em seu poder, na esteira do já explicitado pelo Min. Moreira Alves, são mais do que suficientes para atestar a consumação.

Ficou comprovada a existência do crime de furto qualificado e sua autoria.
A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de avaliação de fls. 67, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 03, pelo laudo pericial de fls. 139/142 e, sobretudo, pela prova oral colhida.
A autoria também é certa.

A suposta vítima, Dionísio Bragagnolo, na fase policial disse que "é proprietário do terreno no local dos fatos e nesta data foi contatado pela imobiliária que informou ao declarante que haviam subtraído os fios do poste que fornece energia elétrica para o imóvel. Que após reparar o prejuízo informará o custo com o conserto." Em juízo manteve sua versão. Recuperou parte da fiação.

A suposta vítima, Mariana de Jesus Matos, na fase policial, disse que "é companheira de Fernando Donizetti Savi, conhecido pelo vulgo de Rato. Esclarece, que nesta data juntamente com Fernando se dirigiram ao local dos fatos, onde Fernando escalou o poste, arrancou a fiação e colocou na mochila da declarante. Informa, que participou do furto, porque, foi obrigada e toda vez que se recusa é agredida pelo companheiro possuindo inclusive diversas lesões na cabeça em razão de agressões do companheiro." Em juízo disse que se agrediam mutuamente; discutiam por conta da divisão da droga a ser usada. Discutiam para que ele não roubasse, ele ficava nervoso. As agressões aconteciam pelas discussões e as discussões eram somente por esse motivo. Confirmou que tinha lesões na cabeça; as lesões não decorreram daquele dia. Antes do furto discutiram e brigaram porque ela não queria que ele fosse. Ele pegou os fios, encontrou com ele no meio do caminho; pegou os fios para poder vender e foi encontrada pela polícia. Estavam próximos quando a polícia chegou, mas ele conseguiu correr. Furtava com o réu para consumir drogas.

A testemunha de acusação, o policial militar Felipe Custódio Pereira, na fase pré processual disse que "nesta efetuava patrulhamento de rotina, quando foi acionado via copom para atender ocorrência referente a furto em andamento. Esclarece, que nas adjacências do local mencionado avistaram um casal com as características mencionadas e ao se aproximarem o indivíduo conhecido pelo vulgo de Rato (Fernando Donizetti Savi), fugiu adentrando um terreno com mato. A companheira do suspeito foi abordada sendo identificada como Mariana de Jesus Matos, na bolsa que a suspeita carregava foram localizados 13 metros de fios com 16 milímetros pesando 2 Kg." Em juízo manteve sua versão. Acrescentou que Mariana confessou o furto e levou os policiais até o local; na delegacia, ele afirmou que só participou do furto porque foi agredida. Ouviu Mariana dizendo diretamente ao delegado que participou do furto somente porque foi agredida. Disse que Mariana apontou o imóvel de onde subtraíram os fios. Mariana disse que foi fazer o furto mediante a promessa de agressão; não presenciou a declaração, somente ouviu que ela falou.

A testemunha de acusação, o policial militar Tiago Marcelo Freira, na fase pré processual disse que "nesta data efetuava patrulhamento de rotina, com seu colega de farda ora testemunha, quando foram acionados via copom para atender ocorrência de furto em andamento. Esclarece, que nas proximidades do local mencionado avistaram um casal com as características fornecidas e ao se aproximarem constataram que se tratava do indivíduo de vulgo Rato, conhecido dos meios policiais, porque, tem praticados inúmeros furtos na Cidade. Informa, que ao notar a aproximação policial o suspeito fugiu sendo abordada a mulher identificada como Mariana de Jesus Matos, que ao ser indagada afirmou, que o companheiro havia subido no poste arrancado os fios, colocou na bolsa dela e saíram do local do furto." Em juízo manteve sua versão. Ela foi ouvida na delegacia. Na delegacia estava nervosa com Fernando por conta da situação. Mariana sabia exatamente o local da subtração. A distância entre o local da abordagem e o local do furto distava uns 50m, mas tinha de dobrar uma esquina. Não sabe se há boletins de ocorrência entre Mariana e Fernando.

FERNANDO DONIZETTI SAVI, em juízo, disse que é culpado pelo furto, mas é inocente em relação à tortura. Nunca agrediu Mariana, está com ela há um ano e meio e nunca agrediu; foi casado por 12 anos e nunca agrediu sua mulher. Acabou a droga por volta de 09h30min; saiu pra rua, avistou uma fiação e subtraiu para vender e aliviar o seu vício; quando estava saindo se deparou com Mariana e discutiram. Policiais mentiram que o viram correndo. Mariana não foi agredida recentemente. Acredita que as lesões sejam decorrentes de agressões antigas; Mariana tem anemia aguda, o que faz surgir várias lesões em seu corpo. Enquanto praticava o furto Mariana ficou em casa; ela que o encontrou após o furto; ela o encontrou quando estava de frente ao local. Enquanto pegava os fios ela não estava lá. Para subtrair os fios subiu uma pilha enorme de tijolos. Não há nenhum boletim de ocorrência de

Mariana contra ele a respeito de violência doméstica. Mariana foi ao seu encontro porque quis.

Não há controvérsias a respeito do furto.

Em relação à imputação de tortura, embora Mariana, grávida hoje do réu, tenha alterado sua versão em benefício do pai do seu filho, o relato em juízo do PM Custódio a respeito da oitiva em delegacia coaduna-se com todo o contexto probatório. De outro lado, a versão dela de que sequer foi ouvida em delegacia ficou completamente sem respaldo nos autos, perdendo credibilidade o seu relato. Além disso, a versão de que encontrou posteriormente o acusado tornaria impossível a sua ciência a respeito do exato local da subtração impossível. E somente por meio dela a polícia soube precisar o imóvel de onde foram retirados os fios. Trata-se de outra circunstância que retira o valor de seu relato. Por fim, a existência de ferimentos conforme documento de fls. 21/22 corrobora a versão acusatória a respeito do exercício da violência.

Qualificadora da escalada (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal): considera-se escalada a entrada por via anormal, que exige um esforço fora do comum do agente para que se concretize a ação delitiva. Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal é expressamente exigida a perícia, a qual, entretanto, conforme jurisprudência, pode ser substituída por provas testemunhais quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, ela ficou comprovada pelo laudo de fls. 139/142.

Qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal): para sua caracterização é preciso a participação de duas ou mais pessoas na conduta criminosa, incluindo-se no cálculo o co-autor inimputável, o agente não identificado, aquele que age sob escusa absolutória (art. 181 do Código Penal) e até mesmo o coautor ou partícipe que não estava na cena do crime.

Por tais razões, deve incidir também nos casos de autoria mediata em que um dos integrantes da empreitada criminosa está instrumentalizado pelo agente, ou seja, age mediante coação ou erro deste. Afinal, o objetivo da lei é imprimir um desvalor especial à conduta quando praticada por mais de uma pessoa, circunstância que, evidentemente, expõe de forma mais intensa o bem jurídico protegido pelo tipo penal.

É só pensar nos planos de furto que simplesmente não aconteceriam sem a presença de duas pessoas ou sem a divisão de tarefas – inclusive intelectuais – ou aqueles que teriam suas chances de sucesso absolutamente reduzidas sem a contribuição de uma pluralidade de agentes.

Sucesso entendido não só como a desapropriação do bem móvel, mas também a não punição dos criminosos.

Se este desvalor incide quando esta ação se dá mediante indução (participação moral), instigação (participação moral), auxílio material ou acordo e divisão da tarefas entre os integrantes, a fortiori incidirá quando um deles age mediante o domínio da vontade pelo outro. Seria estranho admitir, seja tomando por referência quem executa o delito, seja tomando por referência quem o auxilia ou comanda a ação delitiva, o desvalor para quando se fornece um apoio moral, mas não para quando se obriga ou induz a erro uma pessoa para atuar como instrumento do crime. Surgiria uma dúvida quando o agente que tem o domínio da vontade não auxilia materialmente, não divide as tarefas de execução e sequer fornece um plano de execução àquele que atua como seu instrumento. Nessa circunstância não haveria, prima facie, nenhum incremento na exposição do bem jurídico tutelado pela norma penal, ou seja, não haveria uma maior facilidade na subtração do bem móvel.

Todavia, ao se valer de uma pessoa como instrumento, o autor mediato reduz significativamente suas chances de punição e, por consequência, aumenta as chances de sucesso da empreitada criminosa; e como aumenta pela presença de mais uma pessoa, de rigor a incidência da qualificadora.

Aliás, foi o que se passou no caso presente, em que somente a pessoa utilizada como instrumento foi apresentada no flagrante.

Ademais, ao final, aquele que atua sob erro ou coação, fenomenologicamente ao menos, "age", "concorre"; somente essa sua "ação" não lhe pode ser imputada do ponto de vista da responsabilidade criminal. E este "concurso" é o que exige a lei. De notar que até para um doutrinador como Bitencourt, o qual afirma a qualificadora só incidir quando há "a presença in loco dos concorrentes, isto é, a participação efetiva na execução do crime" (Tratado de direito penal, vol. 3, Cap. I, item 12.1), a incidência da inciso IV do §2º do art. 155 do Código Penal para a autoria mediata não é admitida sob argumento de que em tal hipótese "normalmente, o executor age sozinho" (Tratado de direito penal, vol. 3, Cap. I, item 13 - grifos nossos).

Ora, seria forçoso concluir, portanto, que até mesmo para ele, em situações como a do caso em tela, na qual o autor mediato se faz presente na cena do crime exercendo funções na sua execução, incidiria a qualificadora do concurso de agentes.

No caso em exame, ficou comprovada a participação de duas pessoas.

Impossível a incidência da insignificância, pois o valor dos bens supera um décimo do salário mínimo vigente (fls. 67), não atuando a devolução em favor da pessoa imputada.

A devolução do objeto furtado à vítima não constitui, por si só, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

STJ, AgRg no AREsp 1203702/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018.

Configurado, assim, o delito de furto qualificado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa".

Configurado, também, o delito de tortura, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no ARESp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no RESp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em

28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.

(...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.
TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativos do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, vê-se que a pessoa imputada tem contra si cinco condenações transitadas em julgado, sendo a primeira reincidência específica, as duas seguintes reincidência e as duas últimas maus antecedentes. Elas constam, respectivamente, dos autos 1500026-94.2022.8.26.0472; 0002191-04.2016.8.26.0472; 1500177-02.2018.8.26.0472; 0001080-24.2012.8.26.0472; 0001349-34.2010.8.26.0472. As duas primeiras servirão como caracterização de multirreincidência, sendo as demais valoradas negativamente como maus antecedentes. E sendo três as condenações, fixo a pena na metade do seu intervalo.

Não se aplica aos maus antecedentes o período depurador de cinco anos (Tema 150 da Repercussão Geral do STF – HC 593.818/SC).

Comprovada a circunstância do concurso de pessoas, pela qual a lei confere especial gravidade ao delito dobrando a sua faixa de pena, e bastando a circunstância da

escalada para qualificar o furto, aumento a pena em mais dois anos e 116 dias-multa.

Comprovada a circunstância do furto noturno, para a qual a lei confere especial gravidade para a modalidade simples, pela mesma razão deve ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da figura qualificada; e com especial gravidade; aumento a pena em mais dois anos e 116 dias-multa..

Fixo a pena-base do furto qualificado no máximo legal.

Fixo a pena-base da tortura em cinco anos de reclusão.

Segunda etapa. Presente a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência. Prevalece a última implicando um aumento de 1/6 (um sexto), resultando no máximo legal para o furto qualificado.

Presente a agravante da multirreincidência pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em seis anos e oito meses de reclusão para a tortura.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Não se aplica ao furto qualificado a majorante do repouso noturno.

A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).

STJ, Terceira Seção, REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgados em 25/05/2022, DJe 27/06/2022, Tema 1087 dos Recursos Repetitivos.

Praticados por ações distintas, incide a disciplina do art. 69 do Código Penal. A reincidência específica e a negativa das circunstâncias judiciais, em conjunto com o montante de pena, exigem o regime fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR FERNANDO DONIZETTI SAVI à pena de reclusão, pelo prazo de 14 anos e oito meses, em regime inicial fechado, bem como a 360 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude das condutas típicas descritas art. 1º, inciso I, alínea "b", da Lei nº 9.455/97 e artigo 155, §4º, incisos II e IV, na forma do art. 69, estes últimos do Código Penal.

Nos termos do §5º do art. 1º da Lei nº 9.455/97 aplico a pena de perda do cargo, função ou emprego público (caso a pessoa condenada exerça algum), além da pena de interdição, no dobro do lapso temporal da pena privativa de liberdade relacionada ao delito de tortura, para o exercício de qualquer cargo, função ou emprego público.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar (vide fls. 113/121) estão mantidas. Até porque os riscos só foram neutralizados em razão da privação da liberdade.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes. STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Não se vê, tampouco, em razão do tempo de preventiva (54 dias), qualquer risco de excesso.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 13 de setembro de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA